

1501042-49.2020.8.26.0603
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA
Comarca: Birigui
Foro: Foro de Birigui
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/01/2022
... os fatos, para sua melhor elucidação.

Tráfico de Drogas

A autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas restaram comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fl. 01); o boletim de ocorrência (fls. 02/05); a nota de culpa (fl. 12); o auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); os autos de constatação prévia (fls. 24/25); o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Birigui
Foro de Birigui
1ª Vara Criminal
Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501042-49.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501042-49.2020.8.26.0603
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2175645/2020 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 12499421 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2248/20/309 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2175645 - DEL.POL.BIRIGUI, 2248/20/309 - DEL.POL.BIRIGUI
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RONALDO PINEDA TEIXEIRA
Réu Preso
Tramitação prioritária
Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1501042-49.2020.8.26.0603 (Controle 1183/20).

VISTOS.

RONALDO PINEDA TEIXEIRA, qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 329, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Estatuto Penal, porque, no dia 18 de julho de 2020, por volta das 18h35min, à Rua José Chaim Jorge, Jardim São Conrado, nesta cidade e Comarca de Birigui, trazia consigo 03 (três) porções de cocaína e 19 (dezenove) porções de crack, substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos de constatação prévia de fls. 24 e 25 e exames toxicológicos de fls. 119/121 e 122/124.

Consta ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, RONALDO PINEDA TEIXEIRA, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência aos policiais militares Fernando Nunes Martins e Paulo Cesar de Souza Guisso.

Recebida a denúncia em 17 de agosto de 2020 (fls. 138/139), o acusado foi regularmente citado (fl. 184) e apresentou sua defesa escrita às fls. 144/149. Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 08 (oito) testemunhas arroladas em comum, sobrevindo, ao final, o interrogatório do réu (fls. 311/312).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a parcial procedência da ação, condenando-se o acusado pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e absolvendo-o quanto ao delito do artigo 329, caput, do Código Penal (fls. 316/325). A defesa, por sua vez, pediu a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo, referente ao tráfico de drogas. Quanto ao crime de resistência, sustentou que restou comprovado que o réu não agrediu os policiais, pelo contrário, foi vítima de agressão. Em caso de condenação, requereu a redução da pena, afastando-se os maus antecedentes, bem como a majorante prevista no artigo 40, da Lei nº 11.343/06 (fls. 338/366).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico ilícito de drogas e resistência (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 329, caput, do Código Penal).

A ação penal é parcialmente procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram parcialmente comprovadas.

Considerando que a presente ação penal apura mais de um delito, envolvendo o mesmo réu, passo a analisar separadamente os fatos, para sua melhor elucidação.

Tráfico de Drogas

A autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas restaram comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fl. 01); o boletim de ocorrência (fls. 02/05); a nota de culpa (fl. 12); o auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); os autos de constatação prévia (fls. 24/25); o relatório final (fls. 129/130); os laudos periciais (fls. 119/121 e 122/124); os depoimentos das testemunhas e as indigestas negativas apresentadas pelo acusado em ambas as fases da persecução penal.

O réu, tanto na delegacia, quanto em juízo, negou a prática criminosa. Disse que estava consumindo drogas e, ao perceber a aproximação dos policiais, resolveu deixar o local. Negou ter dispensado porções de crack e afirmou que não vende drogas, alegando que portava somente os três pinos de cocaína, mas eram para consumo próprio. Disse que foi agredido pelos policiais. Quanto ao dinheiro, alegou que pertence a sua esposa (fls. 10/11 e 311/312).

Contudo, a negativa do acusado está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero

expediente utilizado na tentativa de se furtar da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada.

Com efeito, as testemunhas de acusação Fernando Nunes Martins e Paulo Cesar de Souza Guisso, policiais militares, ouvidas em ambas as fases, relataram que realizavam patrulhamento, de motocicleta, quando resolveram abordar o réu, que estava próximo a uma igreja, em um local escuro. Ao chegarem perto, o acusado saiu correndo e, durante a fuga, provocou um acidente entre as motocicletas dos policiais. Viram Ronaldo dispensar no chão uma sacola plástica branca, contendo 19 papелotes de crack, embaladas, prontas para o comércio, além de R\$ 349,70, em notas diversas e um aparelho de celular. Conseguiram deter o réu, após ele se debater, e com ele havia 03 pinos de cocaína (fls. 06/07, 08/09 e 311/312).

Em juízo, acrescentaram que o acusado afirmou que havia recebido certa quantia em dinheiro de amigos e foi em Araçatuba buscar drogas e estava naquele local para entregá-las. Receberam informações de que um indivíduo chamado Ronaldo, havia saído da cadeia há pouco tempo e estava vendendo entorpecentes no bairro (fls. 311/312). O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tais depoimentos somente não terá valor quando se evidenciar o interesse dos servidores na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Verifica-se, pois, que os depoimentos dos policiais infirmaram as alegações do acusado apresentadas em seus interrogatórios, e evidenciam que o réu incidiu na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicarem o acusado, ou em imputar falsamente a ele a prática de conduta definida como crime.

Portanto, o simples fato de serem policiais militares não autoriza o desprezo de seus depoimentos prestados nos autos. Isso porque a suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição, se comprovado de forma segura e objetiva, o que não ocorreu no caso, não bastando mera alegação de que a droga teria sido implantada e de suspeição dos depoimentos por serem os depoentes policiais.

As testemunhas arroladas em comum, Gustavo Antonio da Silva Lima, Roberto Rodrigues de Lima, Rodrigo de Souza Lima e Wellington Brito de Souza e, ouvidas na fase policial e judicial, não viram o acusado dispensar qualquer sacola, nem a apreensão de drogas (fls. 104/105, 117/118 e 311/312).

Como se vê, essas testemunhas não presenciaram a apreensão da droga encontrada com o acusado, nem daquela que ele teria dispensado.

A testemunha Monica de Lurdes dos Santos, ouvida somente na delegacia, disse que conhece o acusado e já o viu usando drogas. Sobre os fatos, viu os policiais agredindo o acusado e também quando um deles foi até o baú da motocicleta e retirou uma sacola plástica branca e dentro dela havia uma outra sacola plástica azul. Viu os policiais encontrarem os pinos de cocaína com Ronaldo. Na delegacia, viu o policial pegar a sacola de dentro da viatura e retirar deleas porções de drogas e conta-las. Não viu Ronaldo dispensado qualquer sacola plástica (fl. 107).

Essa versão, todavia, restou isolada nos autos, além do que não foi confirmada em juízo, razão pela qual não pode prevalecer sobre os elementos de prova colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

Descabida, pois, a alegação de que a droga apreendida pelos policiais teria sido, na verdade, plantada por eles para incriminar o acusado, como já mencionado acima. Aliás, quanto à alegação de que foi agredido pelos policiais, os fatos serão analisados a seguir, contudo, a ocorrência ou não de agressão não tem o condão de afastar a ocorrência do tráfico de drogas.

No que se refere aos entorpecentes, a perícia apontou que consistem realmente em "cocaína" (exame químico-toxicológico de fls. 119/121 e 122/124).

Assim, a quantidade do entorpecentes apreendido, ou seja, 26,53 gramas de cocaína, as circunstâncias da abordagem do réu (denúncias de que o acusado estaria

traficando, tentou fugir quando avistou os policiais e reagiu à abordagem), a forma de acondicionamento das drogas, já prontas para o comércio, a apreensão do dinheiro e celular, estão a caracterizar a traficância.

Quanto ao dinheiro apreendido, o acusado não fez qualquer prova sobre a sua procedência lícita, e não arrolou sua esposa, que seria a dona do dinheiro, razão pela qual, diante da prova acima analisada, não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecentes.

Importante anotar que o simples de fato de a droga não ter sido apreendida em grande quantidade, por si só, não afasta a tipificação do crime de tráfico. Aliás, atualmente, os traficantes vêm utilizando desse modo de agir (distribuição de pequenas porções entre vários entregadores), a fim de dificultar a apreensão da droga e a caracterização do crime de tráfico tornando-se irrelevante o fato de não terem sido encontrados balanças, apetrechos e utensílios utilizados para a embalagem de drogas.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. Lembrando-se que o réu foi denunciado por trazer consigo droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Portanto, a prova coletada nos autos é substancial e convincente, ficando evidente a autoria do crime por parte do réu, nos crimes ora apurados. Lembre-se que, no caso, não se exige o chamado "dolo específico", mas apenas o dolo genérico, restando evidente que o acusado praticava o tráfico de drogas.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, quanto ao crime de tráfico de drogas, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios.

Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado trazia consigo 26,53 gramas de cocaína, distribuídos em 22 (vinte e duas) porções, substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros.

A conduta do réu encontram tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade. Neste ponto, embora tenha alegado que era usuário de drogas, tais alegações não restaram comprovadas, até porque a defesa não juntou quaisquer documentos e não requereu qualquer exame de dependência químico-toxicológico ou de insanidade mental. Ademais, o réu, em seu interrogatório, demonstrou-se lúcido.

Ressalto que, mesmo que se demonstrasse que o réu fosse usuário de drogas, isso, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas. Se o réu é viciado há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Diante desse quadro, a condição de ser a agente usuário não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem.

Resistência.

Quanto ao crime de resistência, a ação penal é improcedente e o réu deve ser

absolvido.

Na delegacia e em juízo, o acusado afirmou que, ao ser abordado e perseguido pelos policiais, foi por eles agredido, com chutes no corpo e na cabeça. Disse que foi encaminhado ao hospital e lá o policial Guisso tentou enforcá-lo e foram dados pontos na sua testa sem anestesia (fls. 10/11 e 311/312). Os policiais Fernando Nunes Martins e Paulo Cesar de Souza Guisso, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, disseram que, em perseguição ao acusado, ocorreu um acidente, ambos os policiais se machucaram. Após, conseguiram deter o acusado, que se debateu bastante (fls. 06/07, 08/09 e 311/312).

As testemunhas Gustavo Antonio da Silva Lima, Roberto Rodrigues de Lima, Rodrigo de Souza Lima, Wellington Brito de Souza e Silvio Cesar Cardoso, ouvidos nas duas fases da persecução penal, afirmaram que viram os policiais partindo para cima do acusado, chutando-o enquanto ele ainda estava no chão. Disseram que o acusado não investiu contra os policiais (fls. 104/106, 117/118 e 311/312).

A testemunha Mônica de Lurdes dos Santos, ouvida somente na delegacia, disse que conhece o acusado e viu os policiais agredindo-o com socos e chutes (fl. 107).

Diante das contradições apresentadas na prova oral, há dúvidas insuperáveis sobre o que realmente aconteceu na data dos fatos, o que enseja a absolvição do acusado quanto a este delito.

Doravante, passo à aplicação da pena quanto ao crime de tráfico de drogas.

Das penas.

O acusado ostenta péssimos antecedentes (fls. 367/368 - Proc. nº 0003181-89.2011.8.26.0077; fls. 368/369 - Proc. nº 0005576-93.2007.8.26.0077; fl. 370 - Proc. nº 0007391-09.1999.8.26.0077; fls. 371/372 - Proc. nº 0008846-43.1998.8.26.0077 e fl. 372 - Proc. nº 0009290-08.2000.8.26.0077), razão pela qual uma das circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe é desfavorável, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 1/2 (metade), resultando em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, nem quaisquer atenuantes a serem observadas.

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de aumento ou diminuição de pena. Ao contrário do que alega a defesa em suas alegações finais, não houve qualquer menção a ocorrência da prática de tráfico de drogas próximo a local de trabalho coletivo.

Ademais, não há como se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porque o réu ostenta péssimos antecedentes, inclusive em crime de igual natureza, o que afasta a aplicação desse benefício. Torno, pois, definitivas as penas em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fica fixado cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de

informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

- 1) ABSOLVER RONALDO PINEDA da imputação que lhe foi feita na denúncia quanto ao crime do artigo 329, caput, do Código penal (resistência), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
- 2) CONDENAR RONALDO PINEDA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 18/07/2020 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contra-senso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugeri-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (deseestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372).

Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem esses argumentos, anoto ainda que a pena fixada ultrapassa quatro anos e o réu ostenta péssimos antecedentes, o que afasta de vez a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O acusado deverá continuar a responder preso a este processo, eis que sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, conforme decisão proferida às fls. 76/81, a cujos fundamentos me reporto, como razão de decidir.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

Como não restou provada a procedência ilícita do dinheiro depositado à fl. 110 (R\$ 349,70), não há como se deixar de reconhecer que se trata de produto do tráfico de drogas praticado pelo acusado, razão pela qual, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o seu perdimento.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supradeterminado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Quanto ao celular apreendido às fls. 13/14, apesar de se tratar de instrumento do crime de tráfico, diante da natureza do objeto, entendo não ser caso de perda em favor do Senad, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Oficie-se também à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento do dinheiro (R\$ 349,70) e a destruição do aparelho celular, instruindo-se o ofício com as cópias.

A incineração dos entorpecentes apreendidos já foi determinada (fls. 76/81) e realizada (fl. 182), nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Por fim, em relação à alegação de que o réu teria sido agredido pelos policiais, a matéria já foi analisada na análise da prisão em flagrante, conforme decisão de fls. 76/81, sendo que, naquela ocasião, determinou-se a expedição de ofício para Corregedoria da Polícia Militar para apuração das agressões.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA